

1501503-46.2021.8.26.0357

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Mirante do Paranapanema

Foro: Foro de Mirante do Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... dos acusados confirmou que eles se dedicam ao tráfico ilícito de entorpecentes, não sendo crível a versão de que seriam meros usuários.

Conclui-se, portanto, que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório, em relação ao delito de tráfico.

Em relação associação (art. 35), restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirante do Paranapanema

Foro de Mirante do Paranapanema

Vara Única

Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, 455, Mirante do Paranapanema-SP - cep 19260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501503-46.2021.8.26.0357 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501503-46.2021.8.26.0357

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2135667/2021 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 17995347 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 355/21/303 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 2135667 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HYURY SILVA FERRARI e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de HYURY SILVA FERRARI, CLEBERSON JOSÉ DOS SANTOS E ERICK HENRIQUE CARDIM MARQUES, qualificado nos autos, por violação ao artigo 33, "caput", e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, isto porque em data incerta, mas antes do dia 18 de maio de 2021, nesta cidade e comarca, associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 18 de maio de 2021, as 15h, na rua Antonio Erivaldo da Silva, n. 595, Vila Vasconcelos, nesta cidade e Comarca, os acusados traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em um tablete de maconha, pesando 368,47g e dois invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 24,82g, conforme autos de constatação preliminar (fls. 26/29) e laudos periciais (fls. 211/216).

Segundo a denúncia, durante patrulhamento de rotina, policiais militares receberam denúncia anônima de que dois indivíduos estariam realizando tráfico de drogas nesta cidade, nas proximidades do Centro de Lazer da Vila Vasconcelos. Além disso, eles estariam transitando numa motocicleta de cor vermelha e sem placa. Diante disso, os policiais realizaram diligências no local indicado e avistaram uma motocicleta Honda CG, Titan, cor vermelha, sem placa de identificação, estacionada na frente de uma residência. Quando se aproximaram do imóvel, através das frestas das grades do portão da frente, os militares avistaram HYURY, CLEBERSON e ERICK cortando um tablete de maconha e, em ato contínuo, ingressaram no interior do imóvel e detiveram CLEBERSON e ERICK. HYURY, por sua vez, ao avistar os policiais empregou fuga, contudo, foi alcançado e capturado pelos policiais. É certo que, durante a fuga ele dispensou duas porções de cocaína que estavam em seu poder. No local foram localizados e apreendidos um tablete de maconha, duas porções de crack, uma balança de precisão, uma faca, um facão e três aparelhos celulares. Na ocasião, entendeu-se caracterizada a situação flagrancial, determinando-se as prisões dos denunciados em flagrante delito.

Os acusados foram apresentados em Audiência de Custódia e, após a manifestação da digna representante do Ministério Público e da doughty Defesa, o auto de prisão em flagrante foi homologado, deliberando-se pela conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva (fls. 112/118).

Foi deferida a ordem, nos autos do Habeas Corpus impetrado, para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, III, VI e V, do Código de Processo Penal (fls. 305/307).

Os acusados foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 249/254, 274/277 e 302/304). A denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2021 (fls. 305/307). Designada audiência para coleta de provas, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e realizados os interrogatórios dos réus (fls. 409/410).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos exatos termos da inicial (fls. 415/424).

A defesa do réu Erick Henrique Cardim Marques postulou a absolvição pelo crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06. Em relação ao delito de tráfico, postulou a aplicação da pena no mínimo legal, da atenuante da confissão, o reconhecimento da

causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e, por fim, a fixação dos regimes aberto com substituição por restritivas de direitos (fls. 432/447).

A defesa do réu Hyury Silva Ferrari, por seu turno, requereu sua absolvição diante da inexistência de provas da intenção de vender a droga apreendida, sendo mero usuário. Assim, postulou a desclassificação da imputação e teceu comentários sobre a dosimetria (fls. 448/458).

A defesa do réu Cleberson José dos Santos também postulou a absolvição diante da fragilidade de provas em relação a ambas as imputações. Subsidiariamente, postulou desclassificação e a diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o regime aberto com substituição (fls. 460/466).

É o Relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva deduzida na presente ação é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/19), pelo boletim de ocorrência (fls. 20/24), autos de exibição e apreensão (fls. 25/29), auto de constatação preliminar (fls. 30/33), auto de análise de aparelho celular (fls. 158/214), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 215/220), bem como pela prova oral produzida.

Igualmente certa é a autoria.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu Hyuri Silva Ferrari negou a imputação. É usuário de drogas e foi na casa de seu amigo Cleberson para consumirem. Não conhecia o Erick, pessoa que se encontrava no local com uma motocicleta vermelha. Assustou com a abordagem policial e correu, mas caiu do muro por estar sob efeito da droga. Tinha apenas uma pequena porção de maconha e não era proprietário das demais drogas apreendidas, não tendo visto ninguém manipula-la.

Erick Henrique Cardim Marques disse que era sua a maconha apreendida, a qual adquiriu nesta cidade pelo valor de R\$ 500,00 para repartir com amigos no sítio. Apenas fumou um baseado na casa de Cleberson. Em nenhum momento manipularam as demais drogas, nem tampouco viu uma balança de precisão no local.

Cleberson José dos Santos negou a acusação. Disse que Erick foi até o local para fumarem um baseado. Quando viu a quantidade de maconha trazida por Erick, pediu para ele sair pois seus pais estavam para chegar. Era proprietário apenas de dois baseados não sabendo de quem era o crack e a cocaína. Não tinha balança de precisão. Instado sobre os diálogos extraídos de seu celular, disse que não se referiam a droga.

Contudo, a versão dos acusados não encontrou respaldo nas demais provas produzidas em ambas as fases da persecução penal.

O policial militar Wilson César Calado disse ter recebido a informação de que duas pessoas em uma motocicleta vermelha, sem placa, estariam transportando droga. Iniciadas diligências, localizaram essa moto em frente, pertencente a Erick, a residência do réu Cleberson. Através das frestas do portão, conseguiram divisar os três acusados fracionando as drogas na área e, ao adentrarem, localizaram uma balança de precisão e uma faca. Hyury tentou fugir e dispensou pedras de crack.

Na mesma toada o depoimento prestado pelo policial militar Lúcio Fernando Lima, o qual enfatizou ter visualizado os três réus manipulando e preparando a droga na parte externa da casa.

As demais testemunhas não presenciaram os fatos.

Oportuno salientar, que inexistem razões para se questionar a validade do testemunho policial, em razão da função que exercem; esta que, aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa do cidadão vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não rebatida por outros elementos de prova.

Neste sentido: "PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não provido" (Apelação criminal nº 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) A condição de as testemunhas serem policiais militares não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). É sabido que o depoimento de policial forma importante elemento de prova quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não podendo ser desmerecido apenas em razão do ofício do depoente. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes, não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Acrescente-se, ainda, que na análise dos aparelhos celulares dos acusados foram encontradas mais elementos a confirmar a traficância por eles realizada.

No celular de Hyury, foram encontradas fotos de preparação de droga (fls. 163).

No aparelho de Cleberson, há extensa conversa com o corréu Erick sobre a venda de entorpecentes (fls. 170/178), conforme se verá mais abaixo, e com o possível usuário Carlos Eduardo Montanheri (fls. 179/188: "O Dudu, ta com o bagulho ainda viado? O cara lá falou que queria pegar um pouco... Tu não apareceu..").

No aparelho de Erick também se localizou conversas com o possível comprador Carlos Eduardo Montanheri (fls. 194/202), que reclama que seu pedido não veio com o peso correto, prejudicando seus ganhos na revenda. O réu, por sua vez, diz que irá repor a quantidade faltante. Na sequência, o comprador diz que quer meio quilo de drogas, ERICK afirma que possui a mencionada quantidade e na sequência discutem a respeito do valor do produto. No dia 04 de maio de 2021, ERICK envia mensagem para terceira pessoa não identificada informando que possui drogas à venda (fl. 204).

Assim, restou bem delineada nos autos, a configuração do delito de tráfico.

Após denúncia anônima, a polícia militar localizou os três réus manipulando considerável quantidade de maconha, a qual seria fracionada em pequenas porções para revenda, utilizando-se da balança de precisão encontrada no palco dos fatos. Logo, pouco importa quem adquiriu a droga: fato é que os réus, com divisão de tarefas, estavam agindo em concurso para atingir o intento comum (venda de droga). A análise das conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acusados confirmou que eles se dedicam ao tráfico ilícito de entorpecentes, não sendo crível a versão de que seriam meros usuários.

Conclui-se, portanto, que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório, em relação ao delito de tráfico.

Em relação associação (art. 35), restou devidamente comprovado o vínculo associativo entre os acusados Cleberston e Erick para o cometimento de tráfico de entorpecentes, conforme se infere da extensa troca de mensagens entre eles, cuja temática era justamente a venda de drogas (fls. 170/178).

A propósito, colaciono trecho dos memoriais do Ministério Público no qual se transcreveu elucidativos segmentos desses diálogos:

"Dia 27 de abril

CLEBERSON - Ta no sítio

- Quer pegar um bagui para vender

- Eu tenho um aqui para vender

- P

- Tem aqui

ERICK - Q tanto

- E bau

- ??

CLEBERSON - É po bom

- Que vc quer

ERICK - 10g

- Tem

CLEBERSON - tem que dia vc quer pegar.

ERICK - Mais quantos vc vai querer

CLEBERSON - Não pô eu quero saber se você quer segurar um pouco entendeu? Segurar um pouco de brita, tem um pouco de brita aqui, boa...

ERICK - Então eu fico

Mais quantos vc quer???

CLEBERSON - depende de quanto e qe

ERICK - Quanto vc tem pá passa mn

CLEBERSON - Bastante

ERICK - Quanta g

CLEBERSON - 50

ERICK - Quantos vc quer em tutu

CLEBERSON - tudo não dá pra passar não pô... passo um pouco pra você, na metade do dinheiro e espero metade.

ERICK - Fico cm 40 pago metade avista e o resto pá 20 da midea

CLEBERSON - Beleza...Vou ajeitar aqui pra você e já entro em contato com você.

Dia 30 de abril

ERICK - Q dia vc vai vim para o sítio

Vê aí prq os cara tá traís querendo

CLEBERSON - Blz domingo encota

Dia 02 de maio

CLEBERSON - Tô jetano vc vai vim aqui em mirante Ze

ERICK - vou buscar aí sin

Dia 03 de maio

Mas onde vc tá morando aí

CLEBERSON - Qui na Pista de esquete

ERICK - Vc ta aí q hrs no seu barraco

Vc n sabe quem quer pegar um BK Baú

CLEBERSON - Trás aí po mais tarde.

Logo, a condenação os acusados Erick e Cleberson pelo delito de associação ao tráfico é medida de rigor.

O mesmo não se diga em relação ao corréu Hyury, em relação ao qual não há prova suficiente do vínculo associativo, restando apenas a prática do delito de tráfico, em concurso com os correús.

Por todo o exposto, dúvida não resta acerca de que os réus CLEBERSON JOSÉ DOS SANTOS E ERICK HENRIQUE CARDIM MARQUES praticaram os delitos previstos nos artigos 33, "caput", e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, ao passo que o réu HYURY SILVA FERRARI praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em relação ao réu HYURY SILVA FERRARI

Atentando para as circunstâncias dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu valor unitário mínimo, dada a sua situação econômica.

Na terceira fase, de acordo com o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelo fato de o réu ser primário, possuir bons antecedentes e não haver provas de que pertença à organização criminosa, promovo a redução de sua pena em 1/2 (metade), tendo em vista a quantidade de droga apreendida, único elemento possível de diferenciação da diminuição estabelecida na lei, perfazendo um total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor unitário.

Torno a pena definitiva diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O valor de cada dia-multa, fixado no mínimo legal, corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Adoto referido regime ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, seguindo entendimento da Corte Suprema cancelou a Súmula 512 e adotou, em sede de Recurso Repetitivo constante do Tema 600 (REsp 1.329.088/RS), a figura do tráfico privilegiado, afastando a hediondez do crime.

Ainda, aplico a determinação do Superior Tribunal de Justiça que decidiu no HC Coletivo n. 596.603, de forma vinculante, a aplicação do referido regime aos beneficiados com o tráfico privilegiado.

Por fim, entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reprovabilidade da conduta praticada pelo réu, a qual traz reflexos negativos à sociedade (artigo 44, inciso III, do Código Penal). Nesta senda: "Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o traficante, longe de ser agraciado com os benefícios reservados a crimes menos graves, deve ser retirado da sociedade, cada vez mais temerosa e abalada com o avanço da criminalidade." (TJSP Apelação n. 0008297-73.2012.8.26.0196. Rel. Alexandre Almeida, j. em 25.03.2015).

Trata-se, certamente, de contexto que retrata a personalidade do acusado, inclusive agindo com desprezo pela vida alheia e pela sociedade, pois se envolveu na prática de delito que fomenta a multiplicação da delinquência, uma vez que, não raro, dependentes químicos recorrem ao submundo do crime para angariar recursos para sustento do vício.

Obtempere-se que o artigo 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, consignando ao final a necessidade de que a substituição seja "suficiente", o que não se vislumbra, repita-se, no presente caso.

Em relação ao réu CLEBERSON JOSÉ DOS SANTOS e ERICK HENRIQUE CARDIM MARQUES

Atentando para as circunstâncias dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o delito de tráfico, 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (quinhentos) dias-multa, no seu valor unitário mínimo, dada a sua situação econômica, para o delito de associação.

Na terceira e última fase, inviável a aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que pelos diálogos extraídos dos aparelhos celulares dos réus, é provado de que eles se dedicam à atividades criminosas.

Diante o concurso material de delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas serão somadas, totalizando 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Torno a pena definitiva diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O valor de cada dia-multa, fixado no mínimo legal, corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o inicial fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII). Aliás, embora não desconheça a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, entendo que, por possuir eficácia "inter partes", o controle de constitucionalidade difuso exercido pelo Supremo Tribunal Federal não vincula as Instâncias inferiores, apenas produzindo efeito naquele julgamento em especial.

Por fim, tratando-se de pena superior a quatro anos de reclusão, inviável a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

DECISÃO.

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na presente ação penal para CONDENAR:

- A) HYURY SILVA FERRARI como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no seu valor unitário mínimo, dada a situação econômica do sentenciado, em regime aberto;
- B) CLEBERSON JOSÉ DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 33, "caput", e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixados no seu valor unitário mínimo, dada a situação econômica do sentenciado, em regime fechado;
- C) ERICK HENRIQUE CARDIM MARQUES como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixados no seu valor unitário mínimo, dada a situação econômica do sentenciado, em regime fechado.

Deixo de aplicar a regra da detração, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736, de 2012, para fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal.

Transitado em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor dos réus CLEBERSON JOSÉ DOS SANTOS E ERICK HENRIQUE CARDIM MARQUES.

Em relação ao réu HYURY SILVA FERRARI, admonitória oportunamente.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Custas ex legis.

P.R.I.

Mirante do Paranapanema, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA